

第7編 ■ 救済手続

第1章 上訴/第1節 上訴一般

刑事訴訟法

No.305

H21-40

(配点:2)

月 日

月 日

上訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 控訴審では、第一審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることができる。
- イ. 被告人が刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをした事件については、検察官から控訴の申立てがなければ、控訴裁判所は、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
- ウ. 第一審における弁護人は、判決の宣告により弁護人の選任の効力が失われるので、被告人のため控訴をすることができず、控訴をするには改めて弁護人として選任される必要がある。
- エ. 第二審の判決に対する上告の申立ての理由は、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定されるので、上告裁判所は、事実の取調べをすることができない。
- オ. 上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
1. ア イ 2. ア エ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

ア 誤っている

388条、404条は、控訴審についても、特別の定めがない限り、第一審公判に関する規定が準用されることを定めている。そして、293条2項は、被告人が弁論をできることを定めている。もっとも、388条は、控訴審においては、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければすることができない旨を定め、404条・293条2項を修正している。その趣旨は、控訴審の事後審制からくる制限にある。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

402条。402条は、被告人のみが控訴した事件については、「原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」とし、不利益変更禁止の原則を定める。その趣旨は、被告人が、刑が重くなることをおそれて上訴をためらうことがないようにという政策的配慮にある。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

355条、最決平4.12.14。第一審における弁護人の選任の効力について、判例は、「弁護人選任の効力は判決宣告によって失われるものではない」としている（最決平4.12.14）。よって、本記述前段は誤っている。次に、355条は、「原審における代理人又は弁護人は、被告人のために上訴をすることができる」と定める。その趣旨は、被告人の利益の為に、代理人に、代理人自身の意思によって行使できる独立代理権を認めた点にある。よって、本記述後段も誤っている。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

405条、414条、393条1項。当事者に権利として認められている上告理由は、405条各号に定める事由に限定されている。その趣旨は、最高裁判所の負担が過重とならない点にある。そして、405条3号は、上告申立ての理由として、「最高裁判所の判例がない場合に、……上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」も挙げている。よって、本記述前段は誤っている。次に、上告審は、純粋な法律審であり、第一審・第二審のような証拠調べは行われないが、事実の取調べを行うことは可能である（414条・393条1項）。よって、本記述後段も誤っている。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

411条1号。上告裁判所は、405条各号に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はイとオであり、したがって、正解は肢3となる。

